



上海交通大学
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
KOGUAN LAW SCHOOL

商业贿赂

内容提要

- 概述
- 法定贿赂行为
- 其他贿赂行为

内容提要

- 概述
- 法定贿赂行为
- 其他贿赂行为

背景

- **2005-2012**年各级工商行政管理局机关全年共查处商业贿赂案件**6.2**万件，平均每年**8**千多件；案件查处数量排名第三，仅次于仿冒和虚假宣传。
- **2014**年，葛兰素史克因违反中国商业贿赂相关法律而被罚**30**亿元人民币，多位公司高管被判有期徒刑。这是迄今为止中国政府针对公司行贿开出的最大罚单。

贿赂

- 贿：财也；从贝有声
 - 《周礼》：金玉曰货，布帛曰贿
 - 主要指一般性财物
- 赂：遗也，从贝各声
 - 《左传》：又会诸侯于扈，将为鲁讨齐，皆取赂而还
 - 范围较广，可以是钱，可以是物，可以是官职
- 现代：私赠财物而有所请托

新《反法》规定

- 第七条 经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：
 - (一)交易相对方的工作人员；
 - (二)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；
中间商，中介等等
 - (三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

新《反法》的规定

- 经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。
- 经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为;但是，经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。

《反法》 定义

- 特征：
 - 主体：经营者
 - 对象：~~对方单位或者个人~~ 93年反法
影响交易的单位或个人 现行反法
 - 行为：贿赂财物或者其他手段
 - 目的：为销售或购买商品

1、主体

- 经营者
- 还应当包括
 - 代表人：
 - 法定代表人
 - 员工
 - 代理人

以被代理人的名义购买相关物品

例如，sjtu购买某外国公司的仪器，往往不是自己购买，因为自己没有相关资质，而是由第三方机构代理进行

2、贿赂的行为

- 行贿
- 还应当包含受贿
 - 《上海市反不正当竞争条例》（2020）第9条规定：“任何单位和个人不得收受、承诺收受或者通过他人收受贿赂，为经营者谋取交易机会或者竞争优势。”

3、行为的手段（1）

- 财物：

- 工商总局：**现金和实物**，包括经营者为销售或者购买商品，假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付对方单位或者个人的财物。
- 最高院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条：**既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益**，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡(券)、旅游费用等。
- **积极的物质性利益**（财产不应当增加而增加）

3、行为的手段（2）

- 其他手段：
 - 工商总局：提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他利益的手段。
 - 消极的物质性利益（财产应当减少未减少）
- 是否应当包括非物质性利益？
 - 升官 应当不属于商业贿赂，归属其他法律，商业贿赂强调物质利益
 - 上学
 - 性贿赂 如果支付某人去购买性服务算，但是其他的没有直接的物质利益不算

4、贿赂的目的

- 商业贿赂
 - 目的是市场中的经济性交易
 - 非经济性交易不属于商业贿赂
 - 升官
 - 提高考试成绩
- 目的的表现形式
 - 销售商品
 - 购买商品
 - 其他行为
 - 所有权不转移的交易：租赁
 - 无交易的行为：贿赂竞争对手不参加投标

法律要件（1）

- 主体适格 是经营者
- 主观故意
- 客观行为
 - 核心行为：贿赂
 - 特殊行为：
 - 回扣、折扣
 - 非法佣金
 - 附赠式贿赂
 - 衍伸行为：
 - 入场费

法律要件（2）

- 客体：多重客体
 - 侵害的直接客体
 - 限制其他经营者公平竞争的机会
 - 经营者自身的商誉
 - 国家的廉洁制度（受贿人为国家工作人员）
 - 侵害的间接客体
 - 消费者利益

内容提要

- 概述
- 法定贿赂行为
- 其他贿赂行为

贿赂行为的表现形式

1. 典型贿赂
2. 回扣
3. 非法折扣、非法佣金

1、典型贿赂行为

- 为谋取非法利益，给予有决定权的代表人以经济利益。
- 问题：
 - 谋取合法利益
 - 收钱不办事

本来就是应该是你的，**但是不放心**，还是行贿了

行为犯？
结果犯？

商业贿赂是行为犯，**只要有相关行为**，就属于商业贿赂

2、回扣

- 回扣是指卖方从买方支付的商品款项中按一定比例返还给买方的价款。
- 类别
 - 直接返还给买方自己（折扣）
 - 返还给买方的代理人、代表人或者其他具有权力的主体（狭义的回扣）
需要规制的对象，折扣一般不需要规制
- 违法性
 - 典型贿赂行为的外延
 - 侵犯客体：其他竞争者公平竞争的机会

帝亚吉欧洋酒行政处罚案

- （沪监管浦字〔2017〕第150201714206号）
 - 2016年帝亚吉欧针对酒吧这一类终端零售商开展了促销。目的是促进Original、Lasanta、18Y、Signet四款酒水的销售。参与活动的十三家酒吧在活动期间实际销售的Original酒每瓶奖励25元、Lasanta酒每瓶奖励50元、18Y酒每瓶奖励75元、Signet酒每瓶奖励100元。
 - 当事人通过第三方公司兑现奖励，由第三方公司为当事人采购了总金额为50万元的银联卡，其中面值1000元的银联卡495张、面值500元的银联卡10张。第三方公司根据当事人的指令，将上述505张银联卡送至十三家酒吧的负责人或者联系人手中。

最终判属于商业贿赂

题外话：我国对于商业贿赂的判定是相对比较严厉的

3、非典型的商业贿赂

- 折扣和佣金（合法行为）
 - 折扣是买卖双方的一种让利行为
 - 佣金是卖方或者买方付给中间人的费用（对应于非法佣金）
- 非典型商业贿赂的表现形式
 - 非法折扣
 - 非法佣金

非典型商业贿赂

合法折扣	合法佣金
• 实质是价格优惠或减价； • 在形式上主要表现为“即时扣除”； • 折扣发生在交易相对方； • 折扣是明示； • 合法的商业惯例	• 佣金支付关系只发生在经营者与中间人之间； • 中间人须具有合法的从事中介业务活动资格的经营 - 者； • 佣金的支付方式是公开的； • 佣金的数额应符合行业惯例。

违法要件

- 《上海市不正当竞争条例》第9条规定：
 - “经营者、交易相对方、中间人支付或者接受折扣、佣金的，**均应当按照相关财务制度如实入账。**”
 - 侵犯客体：是否侵犯其他竞争者公平竞争的机会？
 - 内在原因：
 - 国营经济的延续
 - 破坏财务制度
- **是否如实入账就合法了呢？**

在中国，特别注意区分：账外暗中（非法回扣）与明示入账（合法折扣）

(1) 非法折扣

- 折扣是给予交易相对人的优惠，与回扣有一定的交叉关系。
 - 不入账的折扣破坏财务制度，应当**推定违法**

新疆大仓案

- 新疆大仓经贸有限责任公司与新疆荣利达果品公司不正当竞争纠纷上诉案；新疆维吾尔自治区高级人民法院（2005）新民三终字第23号
- 2004年1月，大仓公司作为蔬菜水果市场经营，给进入其场地经营户发放一定金额的钱款，将经营户拉至其市场进行经营。
- 法院判决：
 - 上诉人大仓公司提供的会计帐册仅有款项的支出，而没有记载收受方的名称和相应的收款凭证，也不能证明帐册上记载的款项就是发放给经营户的补贴款，属于“不如实入账”

入账的折扣呢？

- 甲医院与乙医药公司有长期往来业务，甲医院公开接受（进入了医院的财务帐簿）乙公司赠送的汽车一辆。
- 问题：是否属于回扣？

属于非法回扣

(2) 佣金

- 合法佣金是具有从业资格的中间人引起居间劳务所产生的报酬，既可以由买方支付也可以由卖方支付，也可由双方共同支付。
- 佣金的特点：
 - 支付关系发生在经营者与中间人之间。
 - 中间人具有合法的中介资格。
 - 佣金的支付方式必须公开。
 - 佣金是合法的报酬
- 实践中非法佣金也被称为回扣
 - 导游回扣
 - 医生回扣
 - 老师回扣

佣金一般是合法的

非法佣金

- 要件

- 必须发生在买方或者卖方与中间人之间
 - 否则就为折扣或者回扣
- 中间人不具有从业资格
 - 从业资格如何解释？
 - 收回扣的医生是否具有从业资格？
- 佣金的支付为帐外暗中
 - 是否必须帐外暗中？

工商登记or一般民事主体

一般行业与特殊行业

有从业资格

中间人的从业资格：案例

- **1997年《工商总局关于以收买瓶盖方式推销啤酒的行为定性处理问题的答复》**
 - “啤酒公司以给付金钱等方式向酒店服务员回收啤酒瓶盖，诱使酒店服务员向顾客推销其产品，实质是经营者为销售商品，采用给予财物的方式贿赂对其商品销售有直接影响的人。
 - 其行为在一定程度上排挤了其他竞争者，也极易限制消费者的选择权，损害消费者合法权益，扰乱正常市场竞争秩序，构成商业贿赂行为，应当依法予以查处

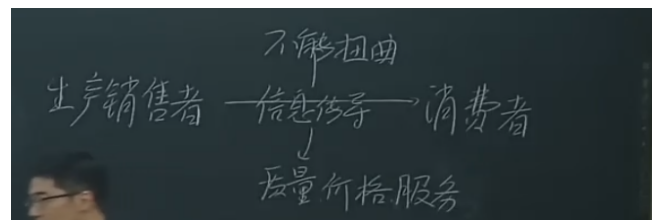
居间人一般须有合法的经营资格。若无相关资质，则可能构成商业贿赂。当居间人虽无资质，但实质上仍从事的是中介活动，且并未损害市场竞争秩序，此类佣金并不构成商业贿赂，而是构成非法经营。

中间人的从业资格

- 从业资格应当从买卖双方是否认可中间人的居间地位为原则
- 收买瓶盖
 - 服务员与啤酒厂存在啤酒推销的居间协议
 - 消费者并未意识到或者不认可服务员具有推销啤酒的地位
- 导游回扣
- 医生回扣
- 教师回扣
- 侵害客体
 - 消费者的选择权
 - 其他竞争者公平竞争的权利

利用职业优势影响消费者选择

商场代销电话卡，通信公司给商场提成构成商业贿赂吗？ 不构成商业贿赂



是否必须以入账为要件？

- 1999年，工商总局在给福建省工商局《关于旅行社或导游人员接受“人头费”、“停车费”等费用是否按商业贿赂行为定性的请示》的答复：
 - 《反不正当竞争法》第8条禁止经营者为销售或购买商品而采用财物或其他手段进行贿赂的行为，其实质是禁止经营者以不正当的利益引诱交易。
 - 经营者无论将这种利诱给予交易对方单位或个人，还是给予与交易行为密切相关的其他人，也不论给予或收受这种利益是否入账，只要这种利诱行为以争取交易为目的，且影响了其他竞争者开展质量、价格、服务等方面的公平竞争，就构成《反不正当竞争法》第8条禁止的商业贿赂。

忠诚折扣

- 同一经销商同时经营多个品牌，某个品牌对于销售达标的经销商施以重奖，无账外暗中行为。
- 反垄断法中的**滥用市场支配地位**的行为。

折扣是一种常见的价格竞争形式,但在本案特定的市场环境下,特别是利乐与其他企业的极不对称的市场地位情况下,总局认定利乐的特有折扣模式使得他借助已有的支配地位,排除、限制了包材市场竞争。在包材市场中,下游企业特别是大中型企业都会向利乐采购一定量的包材。如果某客户已从利乐采购,继续向利乐增加采购量时,不仅单价下调,还能获得返利;其他包材企业为了争取部分增量订单,报价不能仅仅是利乐的那个新单价,还必须大幅度降价才能补偿客户可以获得的利乐返利。利乐的平均价格仍然可以很高,在增量需求部分却表现出很低的价格,增加了其他包材企业的竞争难度。

附赠式贿赂

- 经营者在销售中给单位或者个人赠送现金或者物品。
 - 一个人不应当是消费者 给消费者算是折扣
- 侵犯客体
 - 其他竞争者公平竞争的机会
 - 不以提高质量作为目的的竞争

米其林的政策：4个级别的零售商每采购一个米其林轮胎可以获得80积分（里程），另一级别的零售商每采购一个轮胎可以获得60积分（里程），在促销或是给予特别支持时有时也会给予积分（里程）作为奖励。零售商可以使用上述积分（里程）在米其林零售商俱乐部网站上兑换包括卓越亚马逊卡在内的一些商品。

合法馈赠

- 往来财物的价值大小；
- 发生财物往来的背景，
 - 如为个人，则考虑双方是否存在亲友关系及历史上交往的情形和程度；
- 财物往来的缘由、时机和方式，提供财物方对于接受方有无职务上的请托；
- 接受方是否利用职务上的便利为提供方谋取利益。

总结

- 商业贿赂破坏的法益有两种
 - 排挤公平竞争的其他竞争者：
 - 消费者不应当成为受贿主体
 - 给予消费者好处也不是行贿
 - 破坏正常财务制度 与中国公有制为主的经济现实相关
 - 给予消费者的好处也可能被认为是商业贿赂
 - 但是消费者依然不是受贿主体

新开的商场为了吸引商家入驻，进行场地打折，但是没有入账，算是商业贿赂

内容提要

- 概述
- 法定贿赂行为
- 其他贿赂行为

一、医药行业的贿赂案件

- 赞助医生参加学术会议
- 在医院的设备投放

(1) 赞助医生参加学术会议是否违法？

- 判断是否假借会议赞助来进行商业贿赂需考虑的因素包括：
 - 会议是否真实。
 - 赞助是否与产品采购挂钩。
 - 行程是否安排旅游或高价值的其他服务与礼品。

案例

- 施贵宝于**2015年8月27日**支付上海交通大学医学院附属新华医院心血管内科主任参加“欧洲心脏病学会”往返英国伦敦的商务舱机票费用共计人民币**57,095元**。期间，新华医院心血管内科，向中美施贵宝采购“福辛普利钠片（蒙诺）”等**6种**药品，合计价值人民币**772,536.25元**。

(2) 设备投放问题

- 设备免费赠送

- 在约定设备投放期内，医院则需向供应商购买该设备配套试剂、耗材，采购量达标；不达标，则需按照约定部分支付或全部支付设备的对价。

- 设备免费租赁

- 如果向客户采购设备配套试剂或耗材数量达标，则无需支付租金；不达标，则需按照约定支付租金。

实践处理

- 工商总局竞争执法局在**2017年8月21日**发布《关于进一步加强医药领域不正当竞争案件查处工作的通知》，在第一条中明确提出
 - “严肃查处假借租赁、捐赠、投放设备等形式，捆绑耗材和配套设备销售等涉嫌商业贿赂不正当竞争行为”。
 - 如果投放设备“捆绑耗材和配套设备销售”，工商总局竞争执法局的态度是构成商业贿赂。

二、入场费

- 大型零售商在商品定价外，向供货商直接收取或从应付货款中扣除，或以其他方式要求供货商额外负担的各种费用。
- 包括：进场费、新品上架费、新店开业赞助费、店庆赞助费、媒体广告费、落地陈列广告费、快讯赞助费、各类节庆费、无条件返利、新店开业折扣、损耗补偿等费用。

家乐福事件

- **2003年6月**上海炒货企业与家乐福超市因为入场费的问题发生争执，**9家**炒货企业联合起来和家乐福超市进行谈判，要求改变现有的供货方式。
- 家乐福超市收取“法国节日费”“信息更换费”等。曾要求供货商支付每家店人民币**2万元**的“老店翻新费”，但在具体执行过程中，既没有让厂家对老店翻新进行确认，也没有征得供货商的同意，而是超市单方面认定并在供货商结算款中对此费用进行扣除。
- 而家乐福超市则以收取入场费是“国际惯例”为由加以拒绝。
- 通过协商之后双方仍然无法达成共识，阿明、正林、洽洽等占**全国炒货市场8成**份额的**10家**著名炒货企业停止向家乐福供货。在此之后，全国**10多家**行业协会对炒货行业协会表示声援，使“家乐福进场费事件”波澜突起。

家乐福收费的大致构成如下表

费用名目	金额
法国节日店庆费	每年10万元
中国节庆费	每年30万元
新店开张费	1万元至2万元
老店翻新费	1万元至2万元
DM海报费	每年2340元
堆头费	每家门店2000元
新品费	每家门店进一个新商品要1000元
人员管理费	每人每月2000元
堆头费	每家门店3万至10万元
出厂价让利	销售额的8%
服务费	占销售额的1.5%-2%
咨询费	约占2%
排面管理费	2.5%
送货不及时扣款	每天千分之三
补损费	产品保管不善，无条件扣款
无条件退货	占销售额的3%至5%
税差	占5%-6%
补差价	在任何地方只要发现有一家商店的炒货价格低于家乐福，企业必须给予家乐福相当数额的罚金

《零售商供应商公平交易管理办法》(2006)

- 第十三条 零售商不得收取或变相收取以下费用：
 1. 以签订或续签合同为由收取的费用；
 2. 要求已经按照国家有关规定取得商品条码并可在零售商经营场所内正常使用的供应商，购买店内码而收取的费用；
 3. 向使用店内码的供应商收取超过实际成本的条码费；
 4. 店铺改造、装修时，向供应商收取的未专门用于该供应商特定商品销售区域的装修、装饰费；
 5. 未提供促销服务，以节庆、店庆、新店开业、重新开业、企业上市、合并等为由收取的费用；
 6. 其他与销售商品没有直接关系、应当由零售商自身承担或未提供服务而收取的费用。

实际执行情况

- **2011**年关于印发《清理整顿大型零售企业向供应商违规收费工作方案》的通知
- 清理整顿内容包括：
 - 零售商利用市场优势地位，向供应商收取的合同费、搬运费、配送费、节庆费、店庆费、新店开业费、销售或结账信息查询费、刷卡费、条码费（新品进店费）、开户费（新供应商进店费）、无条件返利等均属于违规收费。

郭荷琴诉蒋伟买卖合同纠纷案

- 常州市钟楼区人民法院(2010)钟民初字第1561号
 - 原告为推销商品，而与被告约定由原告向被告支付一定数额的“进场费”，其行为实质上是以不正当的竞争手段排挤、限制他人公平竞争的不正当竞争行为，符合上述法律规章中所规定的商业贿赂的构成要件，应当为法律所禁止。

历史

- 入场费又被称为上架费、通道费等。在美国被称为“**Slotting Allowance**”或者“**Slotting Fee**”。
- 入场费最早出现在**20**年前的美国。当时美国国内的香烟生产厂商为了争取自己生产的香烟能够摆在自动贩卖机上的最佳位置（大约为眼睛位置等高之处）以刺激产品贩卖便开始支付自动贩卖机业者一笔上架费。
- 从上个实际**80**年代之后，入场费成为大型零售企业的惯常操作模式。

入场费的正面效果

- 最佳的零售通道、货架位置是稀缺资源。
- 入场费能够起到过滤低质量产品的效果。
 - 在零售行业中，创新一直是一个有风险的过程。
 - 入场费可以保证制造商谨慎的对待创新。

入场费的负面效果

- 制造商会减弱零售的竞争、提高其利润。
- 大型制造商会排挤小的制造商。
- 上架费所形成的价格歧视对小的制造商和零售商不利。

滥用相对优势地位

- 相对于《反垄断法》中的市场支配地位, 相对市场优势并非是垄断, 而是交易双方相互形成的依赖关系, 对这种依赖关系的滥用造成对一方当事人的不公平, 从而应当受到处罚。
- 适用国家
 - 德国
 - 日本
 - 法国

《电子商务法》 第35条

- 电子商务平台经营者不得利用服务协议、交易规则以及技术等手段，对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向平台内经营者收取不合理费用。

反法第15条

- 第十五条 大型企业等经营者不得滥用自身资金、技术、交易渠道、行业影响力等方面的优势地位，要求中小企业接受明显不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，拖欠中小企业的货物、工程、服务等账款。

反法第15条

- 1) 主体要件：行为主体为大型企业等经营者，而其违法行为针对的对象是中小企业，并非是所有企业；
- 2) 行为要件：滥用优势地位要求中小企业接受明显不合理的交易条件，交易条件包括付款期限、方式、条件和违约责任等；
- 3) 客体要件：侵犯中小企业合法经营自主权；
- 4) 结果要件：拖欠中小企业的货物、工程、服务等账款。

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>